Capítulo 3. Responsabilidad civil. Parte general[15]

1. Persona.

1.1 Definición. Persona humana y jurídica

Todo el derecho, todo el universo de hechos y actos que como consecuencia tengan efectos jurídicos, mantiene como centro a la persona. Inevitablemente el ser humano, al tener que relacionarse en su vida, desarrollará una red de vinculaciones con sus semejantes, y en su desarrollo generará, modificará o extinguirá los derechos que posee. Es por esta razón que corresponde analizar en primera instancia a qué o quiénes se considera en nuestro país personas.

Nuestro Código Civil y Comercial de la Nación distingue entre dos tipos de personas: Persona Humana y Persona Jurídica. Ambos tendrán capacidad de actuar, obligarse y contratar, conforme la ley les otorgue dicha capacidad.

La persona humana no se define en el nuevo código, en cambio, a la persona jurídica se la indica como "...todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación." (artículo 141del Código Civil y Comercial).

Según el artículo 19 y 20 del mismo cuerpo normativo, la persona humana comienza su existencia desde su concepción la cual consiste en "el lapso entre el máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo". Desde aquel momento el ser humano "goza de aptitud para ser titular de derechos..." (art. 22 C.C.C.) los que quedarán irrevocablemente adquiridos si naciera con vida, sin importar el tiempo que viviese. Por el contrario, si nace sin vida, se considera que la persona nunca existió (Artículos 20 y 21 del Código Civil y Comercial).

Por su parte, las personas jurídicas son las que disponen los artículos 145, 146 y 148 del Código Civil y Comercial y las demás leyes regulatorias de la materia, como la Ley de Sociedades Comerciales, la Ley de Asociaciones Sindicales, la Ley de Cooperativas, etcétera.

Según el Código Civil y Comercial, las personas jurídicas pueden ser:

---

[15] La adecuación inicial a la normativa del nuevo código fue realizada por la Srta. Florencia Diana. La corrección final es de coautoría con el Dr. Lic. Javier A. Larroudé.

a) Las de carácter público: el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter. Además considera de carácter público a los Estados extranjeros, organizaciones que el derecho internacional Público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona constituida en el extranjero, y la Iglesia Católica.

b) Las de carácter privado: las sociedades, las asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal, y toda otra contemplada en disposiciones del Código o en otras leyes.

Finalmente, corresponde destacar que las personas humana, tanto en el origen como en su término, y en cuanto a su capacidad, tienen un tratamiento jurídico diferente de un país a otro. Lo mismo ocurre con las personas jurídicas.

1.2Capacidad[16]

Durante su existencia, las personas humanas y jurídicas realizarán actos para los que la ley les exige ciertas facultades y les impone algunos límites. De la propia definición de persona surge la *capacidad*, que implica que puede adquirir derechos y contraer obligaciones. A esta capacidad se la denomina *capacidad de derecho*, para contraponerla a la capacidad de *ejercicio*, que es tener facultad para *actuar*, es decir, para ejercer por sí mismo los derechos (contraer nuevos, modificar o extinguir los existentes). Por ejemplo, supongamos que hay un niño de ocho años al cual un tío rico le dona un departamento; como consecuencia de eso, el niño será, sin dudas, dueño de ese departamento (capacidad de derecho); pero no podrá por sí mismo alquilarlo mientras sea menor de edad. Para poder alquilarlo o, jurídicamente hablando, realizar un contrato de locación, debe suplir o subsanar su incapacidad de *ejercicio* a través de la participación de un tutor, que lo representará para poder hacer dicho *acto de administración* (alquilar la propiedad). En este caso son tutores naturales sus padres.

En principio y salvo algunas excepciones puntuales, la *capacidad de derecho* es la norma para las personas físicas y la incapacidad, la excepción.

---

15. Artículo22. "Capacidad de derecho. Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hecho, simples actos, o actos jurídicos determinados".
Artículo 23."Capacidad de ejercicio. Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este Código y en Sentencia Judicial".

En cuanto a la capacidad de ejercicio, se destaca lo normado en los artículos 24, 26, 100 y 101del Código Civil y Comercial.

Los que tienen incapacidad absoluta de ejercicio y no pueden contratar por sí mismos son:

1°. Las personas por nacer.

2°. Los menores que no han cumplido los 18 años. El Código denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió trece años, otorgando a estos ciertos derechos que no se detallaran por exceder los límites de la presente obra.

3°. La persona declarada incapaz por sentencia judicial.

Finalmente, como fue ejemplificado en párrafos anteriores, los incapaces de ejercicio pueden adquirir derechos o contraer obligaciones por medio de los representantes necesarios que les da la ley.

Dichos representantes son:

1°. De las personas por nacer, sus padres.

2°. De las personas menores de edad no emancipadas, sus padres o el tutor que se les designe.

3°. De las personas con capacidad restringida, el curador que se les nombre.

Es importante conocer la capacidad que posee la contraparte en una contratación, por los efectos negativos que puede tener contratar con alguien incapaz. Así, estos efectos del contrato (sanción de nulidad) caerán siempre sobre la parte *capaz* y nunca sobre el incapaz, y pueden producirse graves consecuencias económicas según el objeto sobre el que recaiga el contrato, que deberá soportar quien poseía capacidad al momento de contratar.

Para las personas jurídicas[17], en cambio, la capacidad de derecho estará limitada solamente a realizar actos que estén contemplados en su objeto social, que se encuentra individualizado en su acta constitutiva. Las sociedades son administradas por uno de sus órganos, que estará compuesto por socios o no. Este órgano se denomina *de administración*. La sociedad

[17] Artículo141 del Código Civil y Comercial: "Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación".

ejercerá sus actos sí o sí mediante la intervención de representantes con facultades suficientes que surgen de este órgano de administración.[18] Este tema se profundizará en los próximos capítulos.

1.2.1Patrimonio

Desde su nacimiento toda persona posee un patrimonio. Éste se encuentra constituido por un conjunto de bienes (artículo 16 del C.C.C.: "Bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fueras naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre").[19]

A esto, siguiendo a la doctrina, deben agregarse las *deudas* que gravan el patrimonio, ya que, en definitiva, al contratar a uno le interesa la solvencia real de la contraparte y no la aparente que surge del solo análisis de los *bienes y derechos* que ostente como titular.

Tanto las personas de existencia física como las de existencia ideal poseen un patrimonio. Así, las sociedades, asociaciones, etc., serán consideradas como personas enteramente distintas de sus miembros. Los bienes que pertenezcan a la asociación no pertenecen a ninguno de sus miembros, y ninguno de sus miembros (ni todos ellos) está obligado a satisfacer las deudas de la corporación, si expresamente no se hubiese obligado como fiador, mancomunado con ella, surja de un imperativo legal o sea dictado por sentencia judicial.

Entonces, existiendo esta diferenciación de patrimonios, la sociedad poseerá un patrimonio y los socios, otro totalmente distinto. Los socios poseen derechos respecto de la sociedad pero no son dueños en forma directa de su patrimonio. El Código Civil y Comercial en su art. 143 indica: "Personalidad diferenciada. La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos que expresamente se prevén en este Título y lo que disponga la ley especial".

1.2.2Derecho subjetivo y objetivo

---

[18] Artículo160 del Código Civil y Comercial: "Los administradores responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, por acción u omisión".

[19]Artículo 15 del Código Civil y Comercial: "Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme con lo que se establece en este Código".

El artículo 154 indica: "Patrimonio. La persona jurídica debe tener un patrimonio. La persona jurídica en formación puede inscribir preventivamente a su nombre los bienes registrables."

Dentro del derecho patrimonial podemos distinguir el *derecho de las cosas* y el *derecho de las obligaciones*.

El derecho de las cosas (derecho objetivo) trata las relaciones jurídicas en las que una facultad es ejercida en forma directa sobre la cosa; en cambio, el derecho de las obligaciones trata de relaciones jurídicas entre sujetos que comercian con bienes o derechos y/o se causan daños entre sí (derecho subjetivo).

1.3. Obligaciones

En este afán de relación que se indicó al comienzo del capítulo, las personas generan vínculos jurídicos entre sí, es decir, se generan obligaciones. Nuestro Código Civil y Comercial da una definición de obligación en el art. 724 que reza "La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés". Las prestaciones que constituyen "...el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor."

Las obligaciones son de tres clases de *dar*, *hacer* o *no hacer*. Las obligaciones de dar implican la entrega de una cosa material, las de hacer requieren la ejecución de un acto u obra, y las de no hacer exigen la abstención de realizar determinado acto o conjuntos de actos.

Las obligaciones tienen una causa que les da origen. Así el artículo 726 del Código Civil y Comercial indica: "No hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla, de conformidad con el ordenamiento jurídico".

Resumiendo lo visto en el presente capítulo e intentando darle una orientación práctica podemos indicar que cuando uno contrata y como consecuencia genera obligaciones debe tener en cuenta todo lo contemplado hasta este momento, esto es:

1) Con quién contrata (sujetos, capacidad). ¿Es una persona hábil para efectuar el negocio jurídico pretendido? ¿Qué patrimonio tiene el que se obliga para responder ante eventuales incumplimientos?

2) ¿Qué se contrata? (¿Cuál es la prestación *objeto* de las obligaciones asumidas?) ¿Es legal? ¿Es posible? ¿La persona puede contratar sobre ese tipo de objeto?

3) ¿Qué hecho idóneo la genera? (Causa.)

Estos tres elementos que surgen del primer análisis no por casualidad son los elementos que se reconocen como *esenciales* de la obligación, por lo que, de faltar alguno de ellos, ésta sería inexistente. Estos tres elementos son los sujetos, el objeto y la causa.

La obligación, si es analizada, consta de dos partes principales: la *deuda (ese deber de cumplir que impulsa a pagar)* y la *garantía.*

La garantía es, en principio, el patrimonio del sujeto deudor.[20] Así, al tener en cuenta este patrimonio, un sujeto puede sentirse inseguro de contratar a determinada persona, pese a ser aparentemente conveniente, por cuanto el patrimonio con el que cuenta se muestra *insuficiente* para *responder* ante un eventual incumplimiento. ¿Qué tipo de solución se le encuentra al problema? Existe, por ejemplo, la posibilidad de *ampliar la garantía* mediante la obligación de otro sujeto como *fiador*; la constitución de una prenda o una hipoteca sobre algún bien del deudor (derechos reales de garantía), de un seguro de caución; o cualquier otra solución tendiente a dar seguridad al cumplimiento de la obligación o del contrato. De esta forma, se amplía la garantía de la obligación asegurándose su cumplimiento.

En cuanto al objeto de la obligación es una prestación de dar, hacer o no hacer. Debemos aclarar que no todas las cosas o hechos pueden ser objeto de las obligaciones y de los contratos. Deben ser "la prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extra- patrimonial del acreedor. (art. 725 CCyCN)

1.3.1 Obligaciones solidarias y simplemente mancomunadas

La relación que surge de la obligación (relación obligacional) no se enlaza necesariamente entre un sujeto acreedor y un sujeto deudor puramente. Puede existir pluralidad en una parte, en la otra o en ambas. Además, esta pluralidad puede estar en el origen de la

[20]El patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores. Éste es un principio cuyo alcance significa que, en principio, todos los bienes del patrimonio del deudor responden por las deudas que él tenga. Así, en teoría, si el deudor incumple con su obligación, los acreedores podrán ejecutar sus bienes y cobrarse del producido de éstos. El Código Civil y Comercial consagra expresamente este principio del juego armónico de los artículo 730, inciso c), permite al acreedor obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes; y el artículo 743 que indica "Bienes que constituyen la garantía. Los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero sólo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia".

obligación o ser sobreviniente (es decir, ampliar la cantidad de sujetos luego del nacimiento de la obligación).

Cuando existe pluralidad de sujetos decimos que nos encontramos frente a una obligación *mancomunada*. Ésta puede ser: a) simplemente mancomunada o b) mancomunada solidariamente (artículo 825 y 827 del C.C.C.).

1.3.2 Simplemente mancomunada (artículos 825 y 826)

En esta obligación cada deudor debe pagar su cuota-parte de la deuda y cada acreedor tiene derecho a reclamar sólo su cuota-parte del crédito. En la práctica esto funciona como si fueran distintas obligaciones que conviven en el mismo contrato o en el mismo soporte material.

1.3.3 Mancomunada solidariamente (artículos 827a 849)

En estas obligaciones cada deudor debe pagar en forma íntegra la deuda o cualquiera de los acreedores está facultado para exigir y percibir integro el crédito (según sea solidaridad activa o pasiva).[21]

La elección del tipo de mancomunación puede deberse a una conveniencia de la relación (cuestión comercial, de facilidad de pago, etcétera) y tener origen en el contrato, pero también puede existir la mancomunación con origen legal.

1.3.4Clasificación de las obligaciones

Las obligaciones se clasifican según diversos criterios. Principalmente encontramos:

A) Una primera clasificación general se da según la naturaleza del vínculo que une a las partes. Así, las obligaciones podrían ser *civiles*, porque el derecho les confiere acción para exigir

[21] Hablamos de solidaridad activa cuando ésta se da del lado de los acreedores y pasiva cuando la solidaridad está del lado de los deudores.

su cumplimiento en juicio; o *naturales*, porque, sin ser ejecutables, lo dado en pago en razón de ellas no es repetible[22].

B) Según el tiempo en que deba cumplirse la prestación objeto de la obligación se puede clasificar en *ejecución inmediata* o en *ejecución diferida en el tiempo*. También puede clasificarse en *ejecución única*, cuando el cumplimiento se realice una sola vez; y en *ejecución permanente*, cuando una ejecución pueda ser continuada en el tiempo (la ejecución es permanente, sin finalizar); o en *ejecución periódica*; o en *trato sucesivo*, donde el cumplimiento se va dando en forma escalonada, por lo general con vencimientos mensuales.

C) También podemos clasificar a las obligaciones según su modalidad, es decir, que se encuentran sujetas a alguna condición, plazo o cargo. Sujetar una obligación a una condición implica que la existencia de ésta dependerá de un hecho futuro e incierto (no se sabe si ocurrirá o no). En cambio, sujetarla a un plazo es supeditarla al acaecimiento de un hecho futuro y cierto (el hecho ocurrirá indefectiblemente, aunque exista incertidumbre en la fecha exacta en que ello pasará, por ejemplo, sujetar el cumplimiento de una obligación al día en que se muera alguien o a la próxima vez que llueva). Finalmente el cargo es un obligación accesoria y excepcional que se le impone al adquirente de un derecho.

D) Según la prestación que sea debida en las obligaciones podemos clasificarlas en positivas o negativas (según se deba a un obrar o una omisión de obrar), y según su naturaleza en obligaciones de dar, de hacer y de no hacer.

E) En cuanto al sujeto, las obligaciones pueden ser de sujetos simples o plurales. Las obligaciones con pluralidad de sujetos se llaman *mancomunadas*. En el caso en que se pacte o la ley disponga que cualquiera de los acreedores o de los deudores pueda exigir o deba cumplir con la totalidad de la deuda, dicha obligación será *mancomunada solidaria*.

F) Existe también una clasificación con relación a la interdependencia de varias obligaciones: las que tienen independencia de las demás se llaman *principales*; contrariamente, las que dependen de otra como razón de su existencia se llama *accesorias* (artículo 856 del Código Civil y Comercial).

G) Finalmente, encontramos una clasificación que, por su importancia para los ingenieros y cualquier otro profesional, veremos en un párrafo aparte; tiene que ver con la índole del contenido. De este modo, las obligaciones se clasificarán en *de medios* o *de resultado*.

---

[22]Este concepto siguiendo el espíritu del art. 2538 del nuevo código ya que fue expresamente derogada la mención a las obligaciones naturales; aunque dicho artículo las mantiene vigente indicado que "El pago espontáneo de una obligación prescripta no es repetible."

1.3.5 Obligaciones de medios y de resultado

Son obligaciones de medios aquellas en las que el deudor promete ejercer su actividad, la cual normalmente tiene como consecuencia determinado resultado, que es lo que desea obtener el acreedor, aunque el deudor no garantiza lograrlo.

En las obligaciones de resultado, en cambio, lo que el deudor promete es un objetivo, una consecuencia, un resultado o una obra determinada.

Por ejemplo, si tomamos un contrato de compra-venta, el vendedor se compromete a entregar la cosa y el comprador a entregar el precio pactado. Así, las obligaciones son de resultado. En cambio, si lo que se contrata es la actividad profesional, por ejemplo, un abogado frente a un litigio, éste no puede garantizar un resultado, pero sí que utilizará todos los medios legales para intentar obtener un resultado favorable a los intereses de su cliente.

"Es diferente la producción de un resultado de su eficacia: puede ocurrir que un deudor se comprometa a realizar una obra sin garantizar su eficacia, de modo que cumpla la obligación produciendo algún resultado, aunque éste sea deficiente: por ejemplo, si se obliga únicamente a realizar una excavación para extraer petróleo, cumple cuando el líquido comienza a surgir, aunque fluya en cantidad escasa."[23]

1.3.6 Obligaciones del ingeniero

El ingeniero, como profesional, puede realizar todas las tareas para las que la universidad lo preparó, que usualmente se encuentran reguladas por las normas correspondientes a determinado colegio profesional.

Así, por ejemplo, el ingeniero industrial debe matricularse en el CPII (Consejo Profesional de Ingeniería Industrial); en cambio, el ingeniero en electrónica o en informática debe matricularse y regirse por las normas del COPITEC (Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación).

Si bien el registro y la matriculación del ingeniero constituyen un requisito mínimo y esencial para desarrollar la profesión, no es menos cierto que las obligaciones del ingeniero van a surgir con los diferentes contratos que acuerde en su vida profesional.

Estas contrataciones se regirán por las normas generales del Código Civil y Comercial, en cuanto a lo atinente a la responsabilidad profesional, y en particular deberán atenerse a las

[23]Alterini, ob. cit., pág. 499.

normativas especiales que rijan cada materia, según la especialización del ingeniero y los parámetros específicos de su especialidad y saber. Toda especialización profesional tiene un *estado del arte* que indica los avances que deben respetarse en la forma de realizar las obras o los proyectos, y que los profesionales deben conocer y respetar. Ello exige una permanente actualización profesional que empieza en cuanto se obtiene el título habilitante y continúa durante toda la vida profesional.

El art. 1.768 establece los lineamientos de la responsabilidad profesional liberal disponiendo "La actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado concreto. Cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la responsabilidad no está comprendida en la Sección 7a, de este Capítulo, excepto que causen un daño derivado de su vicio. La actividad del profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad por actividades riesgosas previstas en el artículo 1.757."

También es importante destacar que las responsabilidades siempre van más allá del propio contrato y se extienden a daños que en virtud de éste puedan sufrir terceros, ya sea por aplicación directa de la responsabilidad o por la aplicación de normas de protección al consumidor.

En un plano más amplio, existe también la responsabilidad por daño a los intereses difusos de los ciudadanos, como el daño ambiental que puede ocasionarse en el ejercicio de la profesión, al realizar alguna obra contaminante.

Visto el amplio abanico de responsabilidades, y para evitar caer en el miedo que a lo largo de los cursos varios alumnos manifestaron al conocer esta perspectiva de su futuro profesional, es ampliamente recomendable la contratación de seguros que cubran la posible responsabilidad civil y que mantengan su indemnidad frente a posibles errores, negligencias o imprudencias en que pudiera incurrir en el ejercicio de su profesión y de las que, en definitiva, nadie está exento.

1.3.7 Efectos de las obligaciones

Los efectos de las obligaciones son las consecuencias que éstas poseen y se proyectan sobre el acreedor y deudor.

1.3.7.1 Efectos principales

Con relación al acreedor, la ley da una serie de dispositivos legales para satisfacer su interés. Con relación al deudor tiene efectos que se corresponden con su deber y derecho de

cumplir, como, por ejemplo, rechazar una acción de cobro de una obligación o contrato ya cumplido.

En cuanto a los efectos normales, éstos surgen del artículo 730, incisos a) y b) y 731, del Código Civil y Comercial. El primer inciso otorga al acreedor los medios legales para procurar la prestación debida. El segundo consiste en la facultad de hacer procurar por otro, a costa del deudor, el cumplimiento de la obligación.

Finalmente, encontramos en el artículo 730,inciso c)el *efecto anormal* de las obligaciones: habilitar al acreedor para obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes por los daños y perjuicios sufridos por causa de su incumplimiento. Debemos destacar que las obligaciones nacen para ser cumplidas y que la indemnización de daños y perjuicios es un remedio extraordinario, razón por la cual se la denomina *efecto anormal.*

1.3.7.2 Efectos auxiliares

Por su parte, los efectos auxiliares de las obligaciones buscan mantener el patrimonio del deudor sin alteraciones que lo tornen insuficiente para cubrir las consecuencias del incumplimiento.

Pueden clasificarse en dos tipos:

a) Medidas cautelares o precautorias, que pueden ser solicitadas por el acreedor en un proceso judicial, o incluso antes, y tienen por objeto garantizar que la sentencia a cumplirse pueda tornarse efectiva.

b) Acciones de integración y deslinde del patrimonio, que intentan restaurar un conjunto de bienes cuya solvencia fue reducida por actos simulados (acción de simulación) o fraudulentos (acción revocatoria), o por la inacción del acreedor (acción subrogatoria y directa); y la acción de deslinde, que busca que no se confundan dos patrimonios distintos en perjuicio de los acreedores o de uno de ellos.

1.3.8 Extinción

Las obligaciones tienen una duración. Se entiende que tienen un origen o una fuente, y también un final. Existen muchos medios de extinción de las obligaciones. El Código Civil y Comercial establece de forma enunciativa (puede haber más que los allí nombrados) diversos medios de extinción, a saber:

- Por el pago (artículo 865 y ss.).
- Por la novación (artículos 933 a 941).
- Por la compensación (artículos 921 a 930).
- Por la transacción (artículos 1641 a 1648).
- Por la confusión (artículos 931 y 932).
- Por la renuncia de los derechos del acreedor (artículos 944 a 949).
- Por la remisión de la deuda (artículos 950 a 954).
- Por la imposibilidad del pago (artículos 955 y 956).
- Por dación en pago (artículo 942)

Es importante el tratamiento del tema de la extinción de las obligaciones, pues, junto con la resolución y rescisión del contrato, forma la vía de escape o finalización de la relación contractual/obligacional con la otra parte. Esto es un elemento esencial en la vida profesional de cualquier persona.

1.3.8.1 Pago

El primer medio de extinción es el pago: "...es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación" (artículo 865 del C.C.C.). El cual implica un acto jurídico unilateral tendiente a extinguir situaciones o relaciones jurídicas.[24]

Los legitimados activamente para pagar son: el deudor, sus representantes, sus herederos (en caso de fallecimiento) y los terceros interesados.

En caso de que exista solidaridad pasiva en la obligación que se pretende cancelar, cualquiera de los deudores puede solventar la deuda; nace luego una acción de repetición entre los codeudores en las proporciones en que se habían obligado originariamente.

Quien paga debe tener capacidad de hecho para dicho acto. En los casos de pago por un tercero interesado, éste debe ser una persona que no siendo el deudor sufra un perjuicio jurídicamente protegible en caso de incumplimiento. El pago lo puede realizar cualquiera de los sujetos mencionados, aun en contra de la voluntad del acreedor (artículo 881 del C.C.C.), salvo que éste tenga un interés legítimo en que la obligación sea cumplida por el propio deudor.

[24] Artículo 259 del Código Civil y Comercial: "El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas".

Realizado el pago, satisfecho "el interés del acreedor, extingue el crédito y lo libera" (artículo 880 C.C.C.).

El tercero no interesado puede pagar, pero no puede obligar al acreedor a recibir su pago por carecer de *iussolvendi*, es decir que se requiere la conformidad del acreedor para que dicho pago sea efectivo. En caso de pago hecho por un tercero, el deudor queda desobligado de la deuda original, pero se abren distintos supuestos, ya que el deudor continúa obligado hacia quien realizó el pago (*solvens*). Estos supuestos son los normados por los artículos 881 y 882 del C.C.C.

Quien recibe el pago (*accipiens*) debe ser: el acreedor, sus herederos y los representantes. Dichos sujetos deben tener capacidad de hecho con relación a la administración de sus bienes.

El objeto del pago debe ser idéntico a lo que el deudor se obligó. Así, el artículo 868 del Código Civil y Comercial indica: "El acreedor no está obligado a recibir y el deudor no tiene derecho a cumplir una prestación distinta a la debida, cualquiera sea su valor". Lo mismo ocurre con las obligaciones de hacer, tácitamente incluido en el mismo artículo del cuerpo legal.

El pago también debe ser íntegro, salvo que la obligación permita que sea parcial; en caso contrario el acreedor puede rechazar el pago parcial (artículo 869 del C.C.C.).

Finalmente, el pago debe realizarse en las circunstancias de tiempo y lugar pactadas.

Para acreditar que el pago fue efectuado el deudor necesita contar con el recibo otorgado por el acreedor, en el que deben constar:

a) La firma del acreedor o persona autorizada a percibir el pago.

b) La imputación del pago efectuado a la deuda particular.

c) Las cláusulas o recibos especiales por los cuales se cancele parte o la totalidad de la deuda.

d)Fecha y lugar de efectuado.

1.3.8.1.1 Recibo de capital

"Se presume, excepto prueba en contrario que: a) Si se otorga un recibo por saldo, quedan canceladas todas las deudas correspondientes a la obligación por la cual fue otorgado..." (Artículo899 del Código Civil y Comercial).

Ha de tenerse en cuenta que "el pago puede ser probado por cualquier medio" (Articulo 895 C.C.C.) excepto que se determine lo contrario.

1.3.8.1.2 Pago por consignación

El deudor tiene la obligación de cancelar la deuda pagando en tiempo y forma indicados precedentemente. Pero también tiene el derecho de obtener su liberación de la deuda realizando un pago por consignación.

La consignación procede en tres supuestos enunciados en el artículo 904 del C.C.C:

a) Que el acreedor fue constituido en mora.[25]
b) Que existe incertidumbre sobre la persona del acreedor.
c) Que el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causa que no le es imputable.

Esto no agota las posibilidades de proceder a un pago por consignación, dado que "...el pago con intervención judicial también es posible en otros supuestos, como cuando existe controversia acerca del crédito entre deudor y acreedor, o cuando el domicilio del acreedor es incierto o de acceso riesgoso, etcétera".[26]

1.3.8.2 Por la novación

Dalmacio Vélez Sarsfield define, en el Código Civil, que la novación "es la extinción de una obligación por la creación de otra nueva, destinada a reemplazarla" (artículo 933). Para que este medio funcione se requiere un *animus novandi*. Los elementos esenciales de una obligación son: los sujetos, el objeto y la causa. En la novación, la causa de la nueva obligación es la extinción de la anterior. Así, la novación podrá ser subjetiva u objetiva, según lo que cambie (uno u otro de los restantes elementos).

Los efectos de la novación son extinguir "...la obligación originaria con sus accesorios. El acreedor puede impedir la extinción de las garantías personales o reales del antiguo crédito mediante reserva; en tal caso, las garantías pasan a la nueva obligación sólo si quien las constituyó participó en el acuerdo novatorio" (artículo 940 del C.C.C.). Los accesorios de la obligación se extinguen salvo reserva. En el supuesto de que las garantías sean brindadas por un tercero, es requisito que éste vuelva a prestar su consentimiento; en caso contrario quedaría desobligado con la extinción de la obligación primigenia.

---

[25] "Retraso culpable o deliberado en el cumplimiento de una obligación o deber".
[26] Alterini, ob. cit., pág. 384.Teniendo en cuenta que esta edición trata el régimen del Codigo Civil derogado.

Dados los efectos cancelatorios de la novación, es necesario que surja en forma expresa e indubitada del documento que se redacte. Así indica el codificador: "La voluntad de novar es requisito esencial de la novación. En caso de duda, se presume que la nueva obligación contraída para cumplir la anterior no causa su extinción" (artículo 934 del Código Civil y Comercial).

1.3.8.3 Por la compensación

El artículo 921del Código Civil y Comercial enseña: "La compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas, por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y otra deuda. Extingue con fuerza de pago las dos deudas, hasta el monto de la menor, desde el tiempo en que ambas obligaciones comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensables".

La compensación exige la existencia de dos sujetos que revisten las calidades de acreedor y deudor recíprocamente de prestaciones de dar. Asimismo, implica la existencia de dos obligaciones cuyos objetos sean fungibles recíprocamente. No son compensables cosas que, aunque fungibles, no sean de la misma naturaleza, por ejemplo, no puedo compensar una deuda de una tonelada de maíz con una tonelada de trigo, aunque el valor comercial de ambas sea idéntico (artículo 923 del C.C.C.).

Finalmente, la compensación exige que ambas deudas sean líquidas y de plazo vencido o exigibles. Con liquidez nos referimos a que la deuda esté determinada en su monto o en su consistencia; y con exigibilidad indicamos que el acreedor debe tener posibilidad inmediata de ejecutar la deuda (es decir que ésta no esté supeditada a un plazo, al cumplimiento de alguna condición o que no sea natural).

1.3.8.4 Por la transacción

La transacción es un contrato, por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas, con el objetivo de evitar un litigio, o ponerle fin al mismo.

Para que ocurra esto se deben dar dos supuestos: en primer lugar, que las partes se hagan concesiones recíprocas, es decir que cada uno sacrifique en alguna medida sus pretensiones o sus derechos; y, en segundo lugar, que las partes tengan voluntad de extinguir las obligaciones litigiosas.

Es un acto jurídico bilateral por el cual las partes extinguen las mencionadas obligaciones litigiosas en el momento en que se crea una nueva obligación fruto del acuerdo transaccional.

1.3.8.5 Por la confusión

El Código Civil y Comercial, en su artículo 931, prevé: "La obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona y en un mismo patrimonio".

La obligación queda extinguida total o parcialmente "en proporción a la parte de la deuda en que se produce la confusión" (Articulo 932 C.C.C.).

1.3.8.6 Por la renuncia de los derechos del acreedor

Se da la renuncia cuando el acreedor abdica de algún derecho subjetivo que tiene en su interés particular. Para ello se exige la capacidad de dar y recibir gratuitamente o de contratar, según resulte renuncia onerosa o gratuita.

1.3.8.7 Por la remisión de la deuda

La remisión de la deuda es para muchos doctrinarios una especie de renuncia a los derechos del acreedor. Esta remisión se da cuando el acreedor se considera pagado ficticiamente, entregando el título que acredita la obligación que pudiera haber exigido. De esta forma, eliminando el título de la deuda, se tornaría imposible el cobro por parte del acreedor.

1.3.8.8 Por la imposibilidad del pago

El artículo 955 del Código Civil y Comercial dispone: "La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación, sin responsabilidad...".

En cambio, "...si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados".

De la redacción del citado artículo se infiere la íntima relación que tiene la imposibilidad de pago con el caso fortuito o la fuerza mayor. Esto exige la existencia de la buena fe por parte del deudor y no encontrarse en mora. Como es de aplicación lo indicado del caso fortuito, tampoco debe existir la asunción de éste o la obligación legal que imputa al deudor las responsabilidades derivadas de aquél.

1.3.8.9 Dación en Pago

Consiste en la extinción de la obligación por medio de la aceptación voluntaria por parte del acreedor el pago de una prestación diversa a la adeudada (Artículo 942 C.C.C.).

2. Responsabilidad civil.

Hablar de obligaciones y contratos implicaba, hasta la sanción del nuevo código, tratar el tema de la *responsabilidad* con la pregunta única de ¿Quién debe *responder*?. Se responde a un cuestionamiento previo: ¿quién debe cumplir la obligación preexistente contractual o indemnizar su incumplimiento? ¿O quién indemnizará a un determinado sujeto por los daños que sufrió?. Actualmente, el nuevo Código agrega dos funciones más a la responsabilidad civil, la preventiva y la punitiva.

Así queda establecido un sistema mediante el cual se reconocen tres funciones: preventiva, punitiva y resarcitoria.

1°. Función preventiva

En el artículo 1.710 del C.C.C. consagra el "deber de prevención del daño", el objetivo es evitar que se produzca un daño o en caso de que haya uno, "disminuir su magnitud o no agravarlo".

Se consagra el deber de prevención para toda persona con los siguientes alcances: "toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de: a) Evitar causar un daño no justificado; b) Adoptar buena fe (...); c) No agravar el daño, si ya se produjo" (Art.1.710 C.C.C.)."

Por otro lado, quien interponga la acción judicial, debe acreditar interés razonable en la prevención del derecho que se considera amenazado. Para poder iniciarla deben cumplirse determinados presupuestos:

a) Autoría: "puede consistir en un hecho o una omisión de quien tiene a su cargo un deber de prevención del daño".[27]
b) Antijuridicidad: violación al deber de prevención
c) Causalidad: la amenaza de que se provoque un daño debe poder ser previsible.

2°. Función Punitiva

La función punitiva implica sanciones pecuniarias (es decir, valuadas en dinero), para los casos que se provoque un daño.

Con respecto a la función punitiva, el cuerpo legal en su artículo 1.714 le otorga facultad al juez para que en caso de que "la aplicación de las condenaciones pecuniarias administrativas, penales o civiles respecto de un hecho provoca una punición irrazonable o excesiva", este debe "computarla a los fines de fijar prudencialmente su monto".

Se deja en mano del juez la valuación económica de las indemnizaciones por los daños provocados.

3°. Función Resarcitoria

El Código regula la denominada función resarcitoria, la cual consiste en la reparación del daño generado por la violación del deber de "no dañar" o el incumplimiento de una obligación.

Al igual que la función preventiva, la resarcitoria tiene sus presupuestos:

a) Antijuridicidad: Significa que la acción u omisión dañosa es contraria a lo previsto en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, existen excepciones:

- Ejercicio regular de un derecho
- Legítima defensa propia o de terceros la cual provoca daños a un tercero que no fue el agresor ilegitimo.[28]
- Caso fortuito o fuerza mayor.[29]

---

[27] Código Civil y Comercial. Concordado con el régimen derogado y referenciado con legislación vigente. Exégesis de los fundamentos de la Comisión Redactora y las modificaciones del PEN. Eduardo, A. Zannoni– Marina, Mariani de Vidal, Jorge O.Zunino; Fernando E. Shina; Gloria S. Ramos.- Ed. Astrea, Abril 2015, pag. 461.-

[28] La legítima defensa es válida cuando se utiliza frente a una agresión actual o inminente, ilícita y no debe haber sido provocada. En caso de que provoque daños a un tercero que no es el agresor ilegitimo, este tiene derecho a obtener reparación plena (Artículo 1.718 inc. b) C.C.C.)

[29] En esto casos se provoca un daño menor, inevitable, para evitar un daño mayor. Sin embargo, el damnificado tiene derecho a ser indemnizado en la medida que el juez considere equitativo, es decir, que no necesariamente va a obtener una reparación plena del daño provocado (Artículo 1.718 inc. c) C.C.C)

- Asunción de riesgos, de quien se expone a una situación de peligro para salvar la persona o bienes de otro.[30]
- Consentimiento libre e informado del damnificado, el cual libera de responsabilidad por los daños derivados de la lesión de bienes disponibles (salvo que se determine que fue una cláusula abusiva).

b) Factor de Atribución: A diferencia de la función preventiva, la función resarcitoria tiene como presupuesto al denominado factor de atribución. Implica dos tipos de imputación al provocador del daño: *Objetiva* y *Subjetiva.*

En la imputación *objetiva*, la única forma de eximirse de la responsabilidad es cortando el nexo causal, es decir, demostrando la existencia de alguna de las excepciones del punto anterior. Por ejemplo, si el deudor se compromete con una obligación de resultado (es decir, que promete cumplir con un objetivo, por ejemplo cirugía estética) y este cumple no importa la intención, importa que el resultado prometido no se cumplió.

En cambio, para eximirse de la imputación *subjetiva*, estos son la *culpa* y el *dolo.* En estos casos debe probarse la falta de culpa.

La *culpa* según el artículo 1.724 del Código Civil y Comercial: "consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión."

La definición de *dolo* se encuentra inmiscuida en el mismo artículo determinando que se "configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos".

Como queda expuesto, la diferencia entre los factores de atribución subjetivos es *la intención de generar el daño.* Si bien en ambos casos corresponde la reparación, este factor es el que puede generar una variación considerable en la cuantía de la indemnización. Es decir, la extensión de la responsabilidad.

c) Previsibilidad contractual: Otro factor a tener en cuenta dentro de la valoración de la conducta es que "cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno

[30]Artículo 1.719 C.C.C.: "La exposición voluntaria por parte de la víctima a una situación de peligro no justifica el hecho dañoso ni exime de responsabilidad a menos que, por las circunstancias del caso, ella pueda calificarse como un hecho del damnificado que interrumpe total o parcialmente el nexo causal.
Quien voluntariamente se expone a una situación de peligro para salvar la persona o los bienes de otro tiene derecho, en caso de resultar dañado, a ser indemnizado por quien creó la situación de peligro, o por el beneficiado por el acto de abnegación. En este último caso, la reparación procede únicamente en la medida del enriquecimiento por él obtenido".

conocimiento de las cosas mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias.

Cuando existe una confianza especial, se debe tener en cuenta la naturaleza del acto y condiciones particulares de las partes.

Para valorar la conducta no se toma en cuenta la condición especial, o facultad intelectual de una persona determinada a no ser en los contratos que se suponen la confianza especial entre las partes. En estos casos, se estima el grado de responsabilidad, por la condición especial del agente" (artículo 1.725 C.C.C.).

Ha de tenerse en cuenta que es aplicable sólo a los contratos, con el objetivo de que las partes al momento de la negociación y fijación del precio estén al tanto de los riesgos que asumen. Las excepciones a la regla son la existencia de dolo por parte del deudor, o bien que el contrato sea de *consumo*. (Ver capítulo 4 punto 3.1).

d) Relación de causalidad: Busca analizar la causa eficiente del daño. De esta forma se podrá determinar quién es el autor material del hecho. También sirve para fijar la relación de los daños con el hecho que lo haya causado, para poder imputar al autor. Para lograr eso se realiza un análisis del tipo causa-efecto, descartando los hechos que son meramente posteriores en el tiempo, pero que no guardan relación con el daño. Así se posibilita determinar la existencia de condiciones que permiten o agravan las consecuencias dañosas del hecho antijurídico, llamadas concausas. Estas concausas imputables al sujeto pasivo del daño pueden responsabilizarlo por parte de éste y disminuir la sanción de reparación para con el sujeto activo del hecho dañoso. Por ejemplo, encaso de un accidente de tránsito, si la persona embestida no lleva cinturón de seguridad (lo que constituye su obligación) y, en consecuencia, los eventos dañosos se agravan, puede verse reducida en gran parte la indemnización a percibir en virtud de su inacción y su culpa concurrente.

Ha de tenerse en cuenta, que el fundamento de la reparación consiste, nuevamente, en que la persona debe ser responsable (responder) por los hechos propios que generen daño; o los hechos de terceros por los que se deba responder (por ejemplo, dependientes o hijos) y los daños causados por las cosas riesgosas o viciosas de las que la persona se sirve (por ejemplo, el automóvil). Esta responsabilidad intenta dejar indemne al perjudicado o *volver las cosas al estado anterior al evento dañoso*. Esto no siempre es posible, motivo por el cual muchos *daños* irreparables se terminan compensando en dinero.[31]

[31]Artículo 1.740 del Código Civil y Comercial: "Consiste en la restitución de a situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. La víctima puede optar por el reintegro específico excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en

2.1 Incumplimiento inimputable

Cuando el incumplimiento derive de lo que se denomina un *caso fortuito* o una *fuerza mayor* se elimina la imputabilidad del deudor, por lo que no se deberá responder o se lo hará parcialmente, según el hecho acaecido. Nuestro código, en su artículo 1.730, indica: "Caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado".

Para que se configure el caso fortuito es necesario que éste posea las siguientes características:

a)Imprevisibilidad: Al momento de ocurrir el evento dañoso o al momento de efectuar la contratación, el hecho es imprevisible, ya que no existen razones para suponer su acaecimiento.

b)Sea irresistible o inevitable: Se refiere a que reviste la circunstancia de ser inevitable o de una fuerza tal que sea irresistible. Por ejemplo, los *tsunamis* en Asia son un claro ejemplo de un caso fortuito que, aunque previsible, es inevitable por su fuerza.

c) Que no surja o dependa del accionar del deudor.

La imposibilidad de cumplimiento es tanto física como jurídica, ya que podrían ser las circunstancias de derecho las que lo impidieran.

También se puede clasificar la imposibilidad sobreviniente del caso fortuito en *absoluta* o *relativa* y *total* o *parcial*.

Es absoluta, cuando cualquier persona, no sólo el deudor, se vería imposibilitada de cumplir.

Es relativa cuando la imposibilidad resulta de una particularidad que afecta personalmente al deudor.

Es total, cuando el cumplimiento es imposible.

Es parcial cuando aún se puede cumplir parte de la obligación.

En cuanto al tiempo, puede ser definitivo o temporario; esto último habilitaría al deudor a cumplir luego de cesadas las causas que generan la imposibilidad.

---

dinero. En el caso de daños derivados de la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicaciónde la sentencia, o de sus partes pertinentes, a costa del responsable.

Los efectos del caso fortuito son liberar al deudor de la responsabilidad por incumplimiento. Así, el artículo 1.730 del mismo cuerpo normativo dice: "...El caso fortuito o de fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario...".

Esto tiene cuatro excepciones:

a) Cuando el deudor asumió las consecuencias de un eventual caso fortuito en el contrato, mediante lo que se denomina pacto de garantía o cláusula de responsabilidad.

b) Cuando el caso fortuito fue provocado por el mismo deudor.

c) Cuando el caso fortuito sea posterior a la constitución en mora[32] del deudor.

d) Cuando la misma ley no reconoce la facultad del deudor para invocar el caso fortuito como eximente de responsabilidad.

2.2 Daño. Daños resarcibles

El daño es el cuarto elemento que integra la función resarcitorio. El Código Civil y Comercial en su artículo 1.737 define la existencia de *daño*: "cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva.

La *indemnización* a abonar en virtud de una sentencia dictada en un juicio no es la reparación del daño causado; sino la sustitución del mismo por una suma de dinero equivalente. Existen indemnizaciones *tarifadas* como, si nos refiriéramos a la indemnización por despido laboral, o ésta surge del análisis de las probanzas acompañadas en el expediente.

Este daño, como ya hemos visto, puede provenir del incumplimiento contractual o de la violación de la obligación general de no dañar.

Esta indemnización posee tras caracteres:

---

[32]Para que el incumplimiento imputable al deudor dé origen a la obligación de indemnizar, el deudor debe estar constituido en mora. Esto es un estado en que el incumplimiento se torna jurídicamente relevante. En los supuestos del código se requiere interpelar al deudor al pago para constituirlo en mora; esto debe realizarse por medio privado fehaciente o en forma judicial. Así, el instituto se vuelve operante. El texto del artículo 886 del Código Civil y Comercial es el siguiente: "La mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación. El acreedor incurre en mora si el deudor le efectúa una oferta de pago de conformidad con el art.867 y se rehúsa injustificadamente a recibirlo". La regla de la mora automática no rige respecto de las obligaciones sujetas a plazo tácito, y sujetas a plazo indeterminado propiamente dicho (artículo 887 C.C.C.).

- En primer lugar, es patrimonial y consistirá en dar una suma de dinero, en entregar una cosa o hacer una reparación en especie.
- En segundo lugar, es subsidiaria en el ámbito contractual, por cuanto siempre puede el acreedor exigir el cumplimiento contractual en lugar de solicitar la indemnización por equivalente.
- Finalmente, es resarcitoria porque buscar la reparación no es punitorio, dado que no tiene por efecto sancionar el incumplimiento.

La cuantía de la indemnización va a tener directa vinculación con el daño causado, por lo que es importante entender su definición. Daño es cualquier menoscabo sufrido por la persona en sí misma o en sus derechos. Por supuesto que no todo daño va a ser indemnizable, puesto que el daño ocurrido no es igual al daño jurídico.

Se deben cumplir determinados requisitos para que el daño sea indemnizable, a saber:

a) Daño cierto: el daño debe ser probable en forma objetiva en su existencia. El daño hipotético incierto o de mera conjetura no puede, en principio, ser indemnizado.

b) Daño actual o futuro: el daño debe ser cierto, pero puede no ser actual y solamente ser futuro; no obstante ocurrirá sin lugar a dudas. No importa el tiempo que deba esperarse, pues la consecuencia lógica del hecho dañoso lo generará necesariamente. Sin perjuicio de esta aseveración, jurisprudencialmente se ha receptado la indemnización de la pérdida de chance. Esta indemnización no podrá ser equivalente al fruto posible perdido, sino al porcentaje que ocurre de la pérdida.

c) Daño subsistente: el daño debe subsistir al momento de dictar sentencia. Esto es, que el propio tiempo no lo haya subsanado. Sin perjuicio de ello, el daño subsiste hasta que no lo repare quien es responsable de haberlo causado. Por ejemplo, si alguien tiene un accidente de tránsito y repara su vehículo averiado, el daño es subsistente en el dinero invertido para la reparación, hasta que quien causó el accidente lo abone. Lo mismo ocurre si quien abonó el arreglo es el seguro, lo que le da derecho a reclamar lo invertido a quien causó el daño.

d) Daño propio (perjuicio directo): el daño lo debe haber sufrido personalmente quien solicita la reparación. Esto no implica que no se aplique a los efectos de la demanda lo visto en cuanto a la representación de las personas.

2.3 Extensión de la responsabilidad.

El daño debe ser probado en su existencia (incumbe a quien lo reclama). Si bien también se debe (o es conveniente) probar su cuantía para facilitar la labor judicial, los códigos procesales

de la Nación y las distintas provincias, por lo general, indican que la sentencia debe fijar el importe de los créditos por los daños y perjuicios reclamados y comprobados, pese a que no se demuestre la cuantía de éstos.

Para la evaluación del daño existen distintos métodos que es bueno conocer para un mejor manejo de las contingencias legales que en un futuro le pudieran ocurrir al ingeniero en su vida, tanto personal como profesional.

Así, el daño podrá ser valuado:

a) Legal o por la ley: cuando las indemnizaciones son tarifadas, como las ya citadas del derecho laboral.

b) Convencionalmente: por el método de la transacción, que ya hemos visto en el punto de extinción de las obligaciones tratado más arriba. Este método es de vital importancia a los fines de lograr valuar el daño.

c) Judicialmente: es precisamente el método que implica el dictado de la sentencia definitiva frente al conflicto.

d) Arbitralmente: los códigos procesales contemplan siempre la posibilidad de someter las controversias al proceso arbitral. Esto puede ser de gran utilidad en casos muy especiales o controvertidos que requieran un conocimiento técnico para su entendimiento:someterlos al área de un juez que ignore la materia (técnica, no legal), para cuya sentencia se basará en un dictamen pericial de un profesional del saber técnico que corresponda (pero que no necesariamente será un especialista en el tema puntual a tratar), puede dar resultados imprecisos para ambas partes. Frente a estos supuestos puede ser bueno y útil someter el diferendo a un proceso arbitral de un especialista, cuya conclusión será mediante un *laudo* que podrá ejecutarse por vía judicial como una sentencia.

2.3.1 La reparación no patrimonial

Hemos visto que lo que se busca como principio general es la reparación plena (económicamente hablando) del daño causado (Artículo 1.740 C.C.C.), sin embargo, en este punto debemos tener en cuenta que el Código Civil y Comercial prevé además, la indemnización por las consecuencias no patrimoniales las cuales le corresponde al damnificado directo el reclamo de la indemnización. A este se suman los ascendientes, descendientes y el cónyuge en caso de que del hecho resulte la muerte o sufra de una gran discapacidad el primero (Artículo 1.741 C.C.C.).

2.3.2 Atenuación de la responsabilidad

Seguidamente, el artículo 1.742 prescribe: "El juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla si es equitativo en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho. Esta facultad no es aplicable en caso de dolo del responsable".

El juez tiene la facultad de ordenar una indemnización que sea adecuada a las posibilidades de cumplimiento que tenga el deudor, ya que de lo contrario, si el monto de la indemnización es muy alto y este no puede cumplirlo, podría considerarse un menoscabo irrazonable al autor del hecho en los casos de haber sido con culpa. No están incluidos los casos de dolo por parte del responsable.

2.3.3 Dispensa anticipada de la responsabilidad.

Dispone el art. 1.743 que "Son inválidas las cláusulas que eximen o limitan la obligación de indemnizar cuando afectan derechos indisponibles, atentan contra la buena fe, las buenas costumbres o leyes imperativas, o son abusivas. Son también inválidas si liberan anticipadamente, en forma total o parcial, del daño sufrido por dolo del deudor o de las personas por las cuales debe responder.".

Nuevamente existe la posibilidad de acotar el margen de la responsabilidad personal con las excepciones que indica el citado artículo. Esto permite que ante negociaciones contractuales donde el objeto sea complicado de cumplir puedan pactarse formas de limitar la responsabilidad y, en definitiva, lograr contratar sobre este tipo de objetos dificultosos.

2.4 Distinción de la responsabilidad civil y la penal

Cabe diferenciar la responsabilidad civil de la penal, precisamente por su aspecto de finalidad. La responsabilidad penal busca reprender el hecho delictivo y no guarda proporción entre el daño causado y la cuantía. No existe una equivalencia entre el daño inferido al autor y la infracción medida en términos económicos.

Así, los elementos de la responsabilidad penal serán la tipicidad del acto, la antijuridicidad y la culpabilidad, dejando de lado el daño causado. Más aún, en el derecho penal existen los tipos penales que son sancionados como delitos (acciones de *peligro*), sin que sea necesaria la consecución de un daño real.

Capítulo 4. Responsabilidad. Parte especial

1. Responsabilidad y TIC. Tipos de responsabilidad en Internet: diversos sujetos involucrados. Su responsabilidad

La intromisión de las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, y más específicamente la Internet actual o la web 2.0, hace surgir diversas vinculaciones y grados de responsabilidad antes daños ocasionados con la informática. Debe notarse que es común la frase *libertad de expresión*, que pretende universalizarse para la red de redes, pero no puede olvidarse que el efecto viral de cualquier elemento subido a la web hace que los daños a una persona sean ilimitados e incalculables.

No es lo mismo publicar una difamación en un diario y otorgar en el mismo medio, luego, un derecho a réplica, que subir una foto inoportuna a la Internet, de donde, es muy probable, jamás pueda ser eliminada.

En primer lugar, entonces, corresponde analizar quiénes son los sujetos que pueden llegar a tener legitimación activa o pasiva en la Internet (demandar o ser demandados por su accionar). Así, encontramos a los usuarios, los buscadores de contenidos, los proveedores de contenido, los proveedores de alojamiento y los ISP o proveedores de acceso.

Cada sujeto de los mencionados tiene o puede tener una responsabilidad diferente frente a diversos daños ocasionados en el mismo hecho.

No es éste el lugar para realizar una disquisición sobre si es oportuno, posible o deseable regular o controlar la Internet, aplicar tecnologías de filtrado, de autenticación o identificación. Existen numerosos proyectos legislativos y leyes aprobadas internacionalmente, como las conocidas leyes del gobierno de los Estados Unidos de América, Stop Online PiracyAct (SOPA) y Protect IP Act(PIPA), que han merecido gran cantidad de análisis, repudios y aplausos, siendo fácilmente hallables en la web. Nos limitaremos a esbozar las diversas teorías de responsabilidad que surgen de los actores indicados, en forma somera.

Desde el punto de vista legislativo, la Argentina cuenta con dos leyes que tratan la regulación de la Internet: la ley 26.032, que busca incluir la búsqueda y difusión de información en la red en la garantía constitucional de libertad de expresión, y la ley 25.690, que obliga a los ISP a ofrecer a sus usuarios programas para filtrar contenido no deseado de la web.